

1500398-50.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... do réu Gabriel pelo crime de tráfico de drogas e com a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas quanto ao réu Higor.

Já as Defesas apresentaram memoriais, nos quais em relação a Gabriel foram alegadas preliminares consistente na inviolabilidade de domicílio, ausência de justificativa para abordagem policial. No mérito, alegou-se ausência de provas a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500398-50.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-50.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR MARTINS DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA ANDRADE, qualificado a fl. 04 e HIGOR MARTINS DA SILVA, qualificado a fl. 05, foram denunciados perante este Juízo como incursos nos artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, por volta da 01h00, na Rua Vereador Adelino Breve, nº 158, Chacrinha, nesta cidade e comarca de Ourinhos, agindo em concurso de desígnios, aquele trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 46 porções de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 186,91 g e 29 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 4,94 g, enquanto Higor trazia consigo 03 porções de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 27,01 g, conforme laudo de constatação provisória das drogas acostado a fls. 14/16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados e apresentaram resposta à acusação, Higor com rol testemunhal comum (fls. 192) e Gabriel (fls. 214/215).

Durante a audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogados os réus. Em seguida, a acusação postulou pela parcial procedência da ação em alegações orais, com a condenação do réu Gabriel pelo crime de tráfico de

drogas e com a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas quanto ao réu Higor.

Já as Defesas apresentaram memoriais, nos quais em relação a Gabriel foram alegadas preliminares consistente na inviolabilidade de domicílio, ausência de justificativa para abordagem policial. No mérito, alegou-se ausência de provas a sustentar a condenação, questionando-se a legalidade da conduta policial e o teor da confissão espontânea do acusado. Finalmente, de forma subsidiária, pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com aplicação de regime menos gravoso (fls. 399/410).

A Defesa do acusado Higor requereu a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, pugnando, ainda, o reconhecimento da primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (fls. 412/414).

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de ação penal em que se imputa aos acusados o crime de tráfico de drogas, conforme previsão dos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Em prefácio, observo que a combativa Defesa do acusado Gabriel insurgiu-se em preliminar de mérito, sustentando nulidade processual em decorrência da ilegalidade do ingresso policial à residência do acusado, onde parte das drogas apreendidas no feito foram localizadas.

Todavia, observa-se tratarem-se de alegações genéricas, baseadas em entendimentos jurisprudenciais cujos fatos não possuem qualquer identificação com o caso concreto.

Isso porque, cristalina a existência de fundadas razões para ingresso policial no imóvel por ocasião dos fatos, conforme passo a enumerar.

Inicialmente, destacaram os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante que recaiam contra o réu diversas informações privilegiadas a respeito de seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Aliado a isso, o acusado foi surpreendido em via pública no horário da madrugada, vale dizer, 01h00min (conforme registro no boletim de ocorrência de fls. 08/10), oportunidade na qual mantinha contato com o corréu Higor, mas ao avistar a viatura policial cruzou a rua repentinamente, indo em direção a sua residência, exurgindo daí fundamentos suficientes da existência de ilicitude em curso, justificando a abordagem pessoal ao denunciado, cuja revista resultou na apreensão de drogas em sua posse, restando plenamente configurada a situação flagrancial, que amparou o consequente ingresso no imóvel, revestindo de legalidade a ação policial.

Cabe repisar, os policiais não decidiram entrar no endereço do acusado ao acaso, como alegado pela Defesa, mas o fizeram depois da constatado o flagrante do tráfico.

Ademais, em excerto extraído do Recurso Extraordinário nº 603.616/R0 se pondera: “Nada impede, contudo, que essas informações venham a dar base a pesquisas e, uma vez robustecidas por outros elementos, embasem a busca.

Logo, a tese é coerente com a jurisprudência acerca do lastro mínimo para medidas invasivas.

A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.

O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja, a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.

Há também casos que apresentarão complexidades que ultrapassarão os limites do tema aqui apreciado.

Por exemplo, numa investigação sigilosa, pode surgir a notícia do crime permanente

dentro de residência. No entanto, dar acesso ao dono da casa a todos os dados da investigação pode comprometer o restante das pesquisas. Em tese, poder-se-ia realizar investigação independente, documentando indícios mínimos para a busca e retendo o restante da prova. Os limites dessa prática, no entanto, não são aqui debatidos.

Também é comum que, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, revelem-se situações de flagrante delito não previstas no objeto inicial. Numa busca por drogas, por exemplo, podem-se encontrar armas de uso proibido. Em princípio, o ingresso forçado está autorizado, pelo que não se cogita de vulneração da garantia da inviolabilidade de domicílio. No entanto, novamente, os limites da prática não são aqui debatidos.

Tampouco se pretende aferir a validade de mandados de busca e apreensão coletivos. Esse expediente, que vem sendo usado em operações em favelas e comunidades conflagradas, testa os limites da garantia contra a inviolabilidade da casa de formas que não comportariam análise no presente tema.

Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal "sob autoridade governamental" (under government authority) ou "sob as cores do uniforme" (under color of office) - respectivamente, casos *Amos v. United States*, 255 U.S. 313 (1921) e caso *Johnson v. United States* 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão.

Enfim, há uma infinidade de complicadores que merecem avaliação em separado. Será a casuística que impulsionará o desenvolvimento de jurisprudência para enfrentar os diferentes temas".

Na esteira dessa irretocável e refletida fundamentação, necessário se ater ao que de concreto consta no caso sub judice, na qual se constata que o ingresso policial decorreu do conjunto de elementos fáticos que circundam a abordagem.

Seguindo nessa direção, aplicável à espécie:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/R0, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de

entorpecentes. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ. 5. Recurso ordinário improvido" (RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Não se olvide, ainda, que a legalidade da prisão em flagrante foi analisada oportunamente em juízo, quando restou homologada e determinou-se a conversão em preventiva, oportunidade na qual interveio em defesa dos custodiados a Defensoria Pública do Estado, que sequer aventou ilegalidade do ingresso policial no imóvel. Contra referida decisão, não foi manejado recurso cabível. Ademais, a prisão do acusado foi reapreciada ao longo do trâmite processual, não se verificando qualquer nulidade que gerasse a imediata colocação do réu em liberdade por constrangimento ilegal. Não é só, observo que a Defesa do acusado Gabriel buscou a libertação através de remédio heroico, cujo pedido liminar restou indeferido pela Corte Superior (fls. 242), reforçando a inexistência de constrangimento ilegal decorrente de nulidades processuais pelos atos que levaram à prisão e a instauração da ação penal. Finalmente, ao receber a denúncia, este juízo rechaçou referida preliminar, como se vê na decisão proferida às fls. 276/286, a qual, igualmente, não foi impugnada pelas vias recursais. Dessa forma, com esteio nos fundamentos colimados, rejeito a preliminar, passando ao exame meritório, cujas provas reunidas nos autos autorizam a parcial procedência da presente ação penal. Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de exame químico-toxicológico provisório (fls. 14/16), e definitivo (fls. 186/191). A prova técnica é inequívoca e não foi objeto de discussão das partes. A autoria delitativa, por sua vez, decorre das declarações das testemunhas e das demais circunstâncias do caso. Confira-se. O réu Gabriel Henrique dos Santos Moreira Andrade optou pelo direito constitucional ao silêncio em solo policial, desejando manifestar-se apenas em juízo, oportunidade na qual acabou confessando a prática do tráfico de drogas, admitindo, inclusive, ter vendido os entorpecentes encontrados na posse de Higor naquela oportunidade. Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado Higor Martins da Silva negou que tivesse comprado do corréu Gabriel as drogas localizadas em sua posse, afirmando tê-las adquirido de terceira pessoa, as quais eram destinadas ao seu consumo pessoal. Confirmou que havia solicitado o serviço de um mototaxi, assim como Gabriel, para irem a uma festa, mas não iriam permanecer juntos no evento, relatando que levaria o tablete de maconha para usar no local. Em juízo, mudou parcialmente a versão, admitindo ter comprado os entorpecentes do corréu Gabriel e disse que seriam consumidos por ele. Por sua vez, os policiais militares João Paulo Teixeira dos Santos e Cristiano Ribeiro de Camargo relataram na esfera extrajudicial que realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Josefina quando avistaram os réus conversando na via pública, oportunidade na qual Gabriel atravessou a rua rapidamente parando defronte a sua residência, cujo comportamento ensejou a abordagem. Realizada revista pessoal em Gabriel, foram encontradas no bolso da sua blusa duas porções de maconha e o valor

de R\$ 195,00. Na sequência Higor entregou espontaneamente duas porções de maconha que estavam em sua posse idênticas as encontradas com Gabriel. Já na revista pessoal em Higor foi localizado um tablete de maconha envolto em saco plástico de cor amarela. Posteriormente, com autorização do acusado Gabriel, foi feita busca em sua residência, sendo localizadas embaixo da cama dele, 41 porções de maconha embaladas separadamente em plástico transparente e mais três tablets maiores numa sacola amarela, assim como a encontrada na posse do réu Higor. Havia ainda, em uma sacola menor, 29 porções individuais de crack. Na ocasião, o réu Gabriel admitiu que estava traficando, enquanto Higor afirmou que havia comprado o entorpecente localizado em sua posse de terceira pessoa. Os declarantes ressaltaram que durante a diligência chegaram à residência de Gabriel dois mototaxistas, os quais haviam sido solicitados para levarem os réus a um baile, do que concluíram que os dois iam para referido evento praticarem a venda das drogas.

Durante a instrução processual, as testemunhas ratificaram a dinâmica fática, narrando que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento com a equipe de força Tática pelo bairro Josefina, oportunidade em que, ao adentrar a Rua Vereador Adelino Breve avistaram dois indivíduos conversando defronte uma residência, sendo que um dos indivíduos, ao notar a aproximação da viatura policial, cruzou a via e caminhou em direção a uma residência, motivo pela qual foi efetuada a abordagem dos dois indivíduos. Nesse momento, o indivíduo que cruzou a via foi reconhecido como sendo o réu Gabriel, contra o qual recaíam diversas denúncias sobre a prática do tráfico de drogas naquele bairro, sendo ele revistado e flagrado na posse de duas porções de maconha e a quantia de R\$195,00, enquanto que o outro indivíduo, que permaneceu parado, foi identificado como sendo o réu Higor, o qual retirou espontaneamente duas porções de maconha que estavam no bolso e entregou aos depoentes. No entanto, ao ser submetido a revista pessoal, foi encontrado com Higor outra porção maior de maconha, além da quantia de R\$45,00. Ao ser questionado, Gabriel negou ter mais drogas em sua residência, no entanto, autorizou a entrada dos milicianos no local, o que também foi autorizado pela genitora dele, que acabou saindo para fora da casa durante a abordagem. Na casa de Gabriel foi encontrada uma caixa debaixo da cama dele, a qual continha 41 porções de maconha e 29 de crack, todas embaladas individualmente, tendo o próprio réu Gabriel assumido a propriedade dos entorpecentes e confessado que tudo se destinava à venda, admitindo, inclusive, que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto da venda de drogas. Em seguida, Higor foi questionado se tinha comprado os entorpecentes de Gabriel, o que ele negou, afirmando ter adquirido de terceiros e que o entorpecente seria destinado ao seu próprio consumo, acrescentando que estaria naquele local aguardando a chegada de um mototáxi para ir ao baile do Clube Ourinhense.

As testemunhas Dr. Fernando da Silva Freitas e o investigador de polícia Auro Luiz Netto nada esclareceram sobre os fatos, apenas informaram que os policiais militares, antes de apresentarem à ocorrência policial na DELPOL, não solicitaram autorização para entrada no imóvel residencial, o que também foi informado pela genitora do réu, senhora Nanci Aparecida dos Santos, a qual foi ouvida durante a instrução processual na qualidade de informante e disse que os policiais entraram na casa dela sem autorização dela ou do réu.

Esta é, em síntese, a prova produzida nos autos, através da qual a responsabilidade criminal do acusado Gabriel resto suficientemente comprovada, tanto que ele próprio admitiu em juízo a prática criminosa, confessando tanto a posse e propriedade dos entorpecentes apreendidos na ocasião, como também confessou ter realizado a venda das drogas encontradas na posse do corréu Higor.

Neste ponto, questiona a Defesa técnica a validade da confissão espontânea apresentada pelo réu.

De fato, o valor deste meio de prova é relativo, tendo o juiz plena liberdade de confrontá-lo com os demais elementos dos autos a fim de verificar se é ou não verossímil.

No caso dos autos, porém, não se verifica qualquer indício de ilegalidade, haja vista que o réu apresentou sua versão para os fatos de forma livre, espontânea e sob as garantias do contraditório.

Outrossim, anoto que sua confissão encontra-se em harmonia com a versão apresentada

pelo corréu Higor, o qual informou em juízo que comprou de Gabriel as porções de maconha apreendidas com ele, versão esta ratificada pelas declarações dos policiais militares envolvidos na ocorrência, os quais asseveraram terem flagrado Gabriel mantendo contato com Higor na via pública, durante a madrugada, e em seguida notaram que ele, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou despistar a atenção dos agentes públicos, cruzando a via e caminhando em direção a sua residência, oportunidade em que acabou sendo abordado e flagrado na posse de duas porções individuais de maconha e o valor de R\$ 195,00, enquanto que com Higor foram apreendidas duas pequenas e outra maior da mesma substância ilícita. Acrescentaram, finalmente, que o restante das drogas foi apreendido na residência de Gabriel. Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Diante deste contexto probatório, entendo que a confissão espontânea do réu, porque em harmonia com os demais elementos de prova, também pode servir como suporte à condenação.

Não custa lembrar, outrossim, que a razoável quantidade de entorpecente apreendido na ocasião, bem como a forma de embalagem de parte da droga, constituem fortes indícios da traficância, pois é cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, está repartida em porções individuais para facilitar o comércio a terceiros.

Nesse sentido:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papéletes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Soma-se a esses indícios, a apreensão da importância de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), na posse do acusado Gabriel, cuja origem não restou suficientemente esclarecida, o que, diante do contexto dos autos, produz à conclusão de que foi

obtida através da venda de drogas.

Não bastassem todos esses elementos colimados, anoto que o acusado Gabriel ostenta condenação anterior pela prática da traficância, conforme aponta a certidão de fls. 173/174, revelando que já vem se dedicando ao tráfico há algum tempo, circunstância que analisada “em conjunto com os demais critérios de aferição do consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracterizaria um retorno indevido ao Direito Penal do autor” (Renato Brasileiro de Lima, em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2014, p. 696).

Finalmente, cabe destacar que o vasto arcabouço de provas destacado derruba por terra as oposições defensivas, as quais, ressalta-se, carecem de substrato probatório que as amparem minimamente, revelando-se como mero exercício do direito de defesa sem correspondência com a realidade fático probatória existente nos autos.

Por outro lado, quanto ao acusado Higor, acusação e defesa postularam a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal, e de fato o acervo probatório reunido nos autos conduz a tal desfecho.

Com efeito, o acusado foi flagrado na posse de pequena quantidade de drogas e desde a lavratura do flagrante vem sustentando a posse de drogas para consumo, versão esta que acabou sendo confirmada pela confissão de Gabriel, que afirmou ter vendido as drogas a Higor pouco antes da abordagem policial.

Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo informaram que não conheciam Higor dos meios policiais e que não houve o flagrante de qualquer ato de comércio ou apreensão de qualquer outro objeto que pudesse relacioná-lo ao tráfico ilícito de drogas, o que reforça a versão de posse para consumo.

Diante deste quadro probatório, outra solução não resta senão a desclassificação requerida pelas partes. Por conseguinte, passo a dosimetria da pena do delito de porte de droga para consumo próprio.

O acusado é primário (fl. 169), por outro lado confessou espontaneamente a autoria do crime, razão pela qual, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a ele a pena de advertência.

Já quanto ao réu Gabriel, restando plenamente demonstrado a prática da traficância, passo à fixação da pena na forma prescrita pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra uma condenação definitiva anterior (fls. 173/174), a qual será considerada na fase seguinte como circunstância agravante da reincidência e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, todavia a variedade de drogas apreendidas (crack, subproduto da cocaína - entorpecente de alto poder nocivo à saúde humana - e maconha), devem sopesar desfavoravelmente ao réu. Nesses termos, fixo a pena base acima do patamar mínimo legal em 1/4 (um quarto), isto é, em 06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a agravante da reincidência, que é específica (fls. 173/174). Aqui, algumas considerações devem ser feitas.

Ao julgar o Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, o STJ fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porém não se definiu se aquela tese do repetitivo poderia ser aplicada a qualquer caso de reincidência (genérica e específica).

Nesses termos, a Terceira Seção do STJ não fez diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo oportuno, por isso, aplicar a compensação com a atenuante em ambas as situações.

Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, embora igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. Precedentes (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017).

Assim, conquanto se reconheça a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de acusado reincidente específico, a compensação implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mormente porque a reincidência específica exige maior reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a circunstância atenuante.

Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e sopesando a existência de mais uma atenuante no caso em apreço, mantenho a reprimenda fixada inicialmente, ou seja, 06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno em definitiva, à mingua causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Finalmente, tratando-se de réu reincidente, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, “Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso em apreço, trata-se de réu reincidente (artigo 44, inciso II, § 3º, do CP) e foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP), o que afasta a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, isto é, 16/10/2021, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso V da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA ANDRADE e HIGOR MARTINS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, para:

- a) CONDENAR o acusado GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA ANDRADE como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 703 (setecentos e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
- b) DESCLASSIFICAR a conduta tipificada na denúncia para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, CONDENANDO o réu HIGOR MARTINS DA SILVA a pena de advertência.

Demonstrada a traficância, declaro a perda dos valores apreendidos em poder dos réus (fl. 11/12), em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06.

Quanto ao(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) no feito, não sendo requerida a restituição, no prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, fica, desde já, determinada a liberação, oficiando-se ao r. Juízo responsável pelo setor de depósito, para que promova a destinação legal, na forma dos artigos 516, § 2º, e 517, das NSCGJ e 123, do CPP. Expeça-se o necessário. O réu Gabriel respondeu ao processo preso e deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade dele pelo crime de



tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado. Ademais, notória a gravidade concreta do delito, em razão da quantidade e variedade de drogas traficadas, tratando-se de sentenciado reincidente, como se vê às fls. 173/174.

Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de liberação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudesceu as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

"Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Recomende-se-lhe.

O acusado Higor respondeu ao processo em liberdade, e assim poderá aguardar o resultado de eventual recurso, notadamente diante da decisão desclassificatória proferida.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intimem-se os condenados para o pagamento da multa a eles aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena execução forçada, ficando consignado que o pagamento da multa imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condenar os réus no pagamento de custas processuais.

Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P.I.C.

Ourinhos, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA